

1500197-50.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2026047/2022 - 02º D.P. DIADEMA, 2026047 - 02º D.P. DIADEMA, 167/22/123 - 02º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adeilton Ferreira da Silva

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500197-50.2022.8.26.0537 - Controle nº 2022/000129

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2026047/2022 - 02º D.P. DIADEMA, 2026047 - 02º D.P. DIADEMA, 167/22/123 - 02º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adeilton Ferreira da Silva

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

ADEILTON FERREIRA DA SILVA, qualificado às fls. 20/22, está sendo processado pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 14h10, na Passagem Fera Ferida, altura do nº 20, bairro do Casa Grande, nesta cidade e comarca de Diadema, trazia com ele e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 65 embalagens contendo 30,22g da droga cocaína, 56 embalagens contendo 15,64g da mesma droga, na forma de crack, e 135 embalagens contendo 380,28g da droga maconha, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 18/19 e laudo de constatação provisória de fls. 10/12, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls.56/58), o réu foi citado (fl. 103) sendo apresentada defesa inicial às fls.113/115 pelo Defensor Público nomeado. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 16/05/2022 (fl.117) e certificada a citação positiva do Réu a fl. 103.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu ao final. Encerrada a instrução sem requerimento de diligências, seguiu-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação da pena base acima do mínimo diante da quantidade e nocividade da droga cocaína, contando com a confissão do réu, discordando da redução da pena e também com sua substituição pela pena restritiva de direitos, fixando-se regime prisional fechado, sem direito de apelo em liberdade, além da perda do numerário apreendido.

Já o d. Defensor Público reiterou o pedido de absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, com a atenuante da confissão, com o redutor máximo da pena e sua substituição com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime aberto e recurso em liberdade, até pela detração penal.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, nos laudos de constatação e no definitivo (fls.10/16 e 96/98, respectivamente), ambos positivos para as drogas maconha e cocaína. O laudo pericial do estojo está a fl. 100.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais civis (fls.07/08), diligenciaram até a Passagem Fera Ferida com uma viatura caracterizada, local este conhecido como ponto de vendas de drogas. Ao desembarcarem da viatura e prosseguirem a pé pela referida Passagem se depararam com o indiciado ADEILTON FERREIRA DA SILVA subindo a viela na posse de uma bolsinha do tipo nécessaire em suas mãos. Diante dos fatos procederam à abordagem e a busca pessoal, logrando êxito em localizar na bolsa nécessaire, a qual encontrava-se na posse do indiciado, 65 porções de uma substância de cor branca e sólida aparentando ser cocaína; 135 porções de uma substância esverdeada aparentando ser maconha, 56 porções de uma substância petrificada aparentando ser crack, além da quantia de R\$45,00. Ao Indaga-lo informalmente, o indiciado confessou a prática delitiva, inclusive afirmando ter

saído do sistema prisional recentemente e que iria comercializar drogas no local da prisão visto estar desempregado e sem moradia.

Sob o crivo do contraditório o policial Adeilton Ferreira da Silva reiterou que foram até o local, que já é conhecido como ponto de venda de drogas e se depararam com o réu na viela, com uma bolsa em mão, e dentro daquela estavam as drogas e confessou a traficância alegando que ainda não tinha vendido nada embora estivesse com quarenta e cinco reais. Essa foi a terceira prisão do réu no mesmo local. Depois o réu disse que o dinheiro era da traficância. O horário da prisão não é de troca de turno, que geralmente se dá das oito às vinte horas. Supõe que o réu já teria até pego mais drogas. A Avenida Maria Cândida tem várias vielas e acredita que o réu se dirigia à viela para esconder os entorpecentes.

Neste sentido foi o depoimento judicial do policial Álvaro Malagutti Jr. alegou que o local é uma travessa já conhecida como ponto de venda de drogas. Avistaram o réu com uma pochete na mão. Abordado, não reagiu. Na bolsinha estavam as drogas e uma quantia de quarenta e cinco reais. Ele confessou a traficância e que havia saído da prisão, sem trabalho, precisava de dinheiro.

O réu, em solo policial (fl.20) confessou que encontrava -se no local para comercializar drogas, contudo, não havia iniciado suas atividades. Que a maconha seria comercializada por R\$ 5,00, o crack R\$ 5,00, a cocaína R\$ 10,00. Já o dinheiro declarou ser proveniente da traficância. Informou ainda que já foi preso pelo mesmo tipo penal.

Em juízo o acusado alegou ter ficado na campana e o rapaz foi almoçar e então ficou na viela. Viu que subiu um carro Citroen prata e alguém gritou, molhou. Subiu a viela e se deparou com os policiais e assumiu. O rapaz deixou as drogas consigo enquanto foi almoçar. Estava tentando ganhar dinheiro porque tem um filho. Mora na rua de cima, e da outra vez que foi preso, foi absolvido e da outra vez estava na rua de baixo, com os meninos, e assumiu também.

Logo, o interrogatório com a confissão do acusado, que não é prova única, pois veio corroborada pelos depoimentos dos testemunhos - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem prova contrária.

Não bastasse isso, é cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento, consoante Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do STJ.

Ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares trazer consigo e guardar, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Afasto tese de situação de pobreza ou desemprego, pois os bens jurídicos são desproporcionais, por se colocar em risco a saúde pública, de interesse da sociedade, em detrimento do interesse individual, além de se tratar de crime de perigo abstrato. Ademais: não há provas nos autos de que o apelante passasse por miserabilidade extrema a ponto de ter que violar a lei para sobreviver. A mera dificuldade financeira não autoriza ninguém a praticar delitos (TJSP, Apelação Criminal n.º 0006727-87.2004.8.26.0081, Rel. Caio Ferraz de Camargo Lopasso, 5.^a Câmara Criminal D.J.E., j. em 29.07.2011). E admitir a falta de emprego como causa

excludente de ilicitude seria legalizar a prática de crimes por todo e qualquer indivíduo que esteja desempregado e em precárias condições econômicas - o que não é aceitável.

Tão pouco há de se falar em vício ou ser o réu um usuário contumaz de drogas, dado que não há prova nesse sentido, e sequer o réu alegou tal situação. Pelo contrário, disse que recém saído da cadeia, não tinha trabalho, e tem um filho para sustentar, indicando assim que optou pelo serviço da mercancia ilícita porque não foi chamado para trabalhar num lícito, estando no aguardo.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza da droga (cocaína), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), o numerário apreendido (fl.18), são fatores que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito a não demandar aumento inicial na pena, mas a excessiva quantidade de droga apreendida (256 invólucros totais), às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, e valendo-me do princípio da proporcionalidade, ou seja, quanto mais narcóticos apreendidos maior a punição, somado à má personalidade do agente, que solto recentemente, tornou a delinquir no mesmo crime e local, donde fixo em primeira fase, a pena base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea a reduzir a pena ao mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa) ante a ausência de circunstâncias agravantes a se considerar.

Em terceira fase, não concorrem causas de aumento de pena. Quanto ao privilégio previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, o Réu faz jus ao beneplácito legal, porquanto seja primário (fls.42/46), mas considerando a apreensão de quantia razoável de dinheiro proveniente de efetivas vendas de drogas a usuários, disseminando e contribuindo com o vício em drogas de alto poder viciante e degradante da saúde humana, como o crack e a cocaína, além de já ter sido preso por três vezes, sempre na mesma biqueira, por envolvimento com o tráfico, entendo que o redutor de 1/6 é o razoável e proporcional à maior dedicação do réu à traficância ilícita, totalizando assim 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo atual tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

Incabível a benesse do art. 44 do CP, quer por ausente o requisito objetivo (pena supera os quatro anos máximos permitidos) além de não se mostrar suficiente nem eficaz à reprovação da conduta do agente, menos ainda socialmente recomendável sob pena de potencializar a sensação de insegurança e intranquilidade social, a merecer maior reprovabilidade a conduta, dado que viola mais intensamente o bem jurídico tutelado, somado ao elevado número de ocorrências de tal natureza conferindo constante desassossego à sociedade, a exigir firme repressão do Estado como forma de desestimular o crime, geralmente cometido graças ao nível de organização próprio daqueles que fazem do tráfico seu meio de vida. Não bastasse isso, artigo 44, caput, da Lei de Drogas veda, expressamente, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o condenado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37 (HC 144.915/MG, Rel. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010).

A teor do disposto nos artigos 33, do Código Penal, fixo o regime prisional fechado, considerando a reiteração criminosa do agente, e a preponderância da natureza e da quantidade da droga, especialmente a cocaína/crack, não ficando o juiz obrigado a fixar regime inicial relacionado unicamente com o quantum da pena,

podendo optar por um mais gravoso ao observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006. Nesse sentido tem-se: Conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não constitui bis in idem a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional.” (AgInt no REsp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019).

Reconheço a custódia cautelar do Condenado desde a data do fato, sem reconhecer-lhe direito à detração penal ou à progressão de regime, tendo em vista os critérios legais objetivos e a falta de atestado de bom comportamento carcerário atualizado. Assim, deixo de me manifestar sobre a detração penal dos acusados, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais.

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, estando desempregado, sendo incongruente solta-lo, inclusive para a segurança pública e para a conveniência da aplicação da lei penal. Recomende-se-o no cárcere em que está. (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC n.º 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC n.º 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC n.º 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC n.º 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra ADEILTON FERREIRA DA SILVA, qualificado às fls. 20/22, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, e o faço para condená-lo à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 416 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

O acusado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere em que está.

Sendo ele beneficiário de acesso gratuito à Justiça, reconheço suspensão a exigibilidade de custas e despesas processuais, por ora.

Decreto a perda de valores apreendidos nestes autos (fl.18), com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa,

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Diadema, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA